

1501650-25.2021.8.26.0599

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos
Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Magistrado: Flavia de Cassia Gonzales de Oliveira
Comarca: Piracicaba
Foro: Foro de Piracicaba
Vara: 2ª Vara Criminal
Data de Disponibilização: 08/03/2022

... RECURSO ORDINÁRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. INVASÃO DE DOMICÍLIO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DAS PROVAS. CRIME PERMANENTE. FLAGRANTE DELITO. FUNDADAS RAZÕES. ATUAÇÃO DE GUARDAS MUNICIPAIS. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. [...] 4. "É assente nesta Corte Superior de Justiça a orientação de que os ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA de Piracicaba
Foro de Piracicaba
2ª Vara Criminal

Rua Bernardino de Campos, 55, Sala 05/07, Alemães - CEP 13417-100, Fone: (19)3433-4177, Piracicaba-SP - E-mail: piracicaba2cr@tjsp.jus.br
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

TERMO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO, DEBATES E JULGAMENTO

Processo Digital nº:

1501650-25.2021.8.26.0599

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2294403/2021 - 02º D.P. PIRACICABA, 21082265 - 02º D.P. PIRACICABA, 4154/21/518 - 02º D.P. PIRACICABA, 2294403 - 02º D.P. PIRACICABA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JOSE GABRIEL DA SILVA ALVES

Vítima:

SAÚDE PÚBLICA

Artigo da Denúncia:

*

Réu Preso

Tramitação prioritária

Aos 08 dias do mês de março de 2022, à hora designada, por meio da Ferramenta Microsoft Teams, nos termos do Comunicado CG 284/2020, apresentaram-se a Exma. Sra. Dra. FLAVIA DE CASSIA GONZALES DE OLIVEIRA, MMª Juíza de Direito, o representante do Ministério Público, Dr. Rafael Augusto Pressuto e o(a) Defensor(a) Público(a), Dr(a).Daniela Batalha Trettel. Apresentados o(a)(s) acusado(a)(s) JOSE GABRIEL DA SILVA ALVES e as testemunhas arroladas em comum pelas partes Francisco Dernival Miranda Júnior e Felipe Vieira Alves.

Fica consignado que foi assegurado o direito de entrevista do(a)(s) acusado(a)(s) com seu(sua)(s) defensor(a)(es), em reunião virtual apartada, no estrito cumprimento do artigo 185, § 5º, do C.P.P., tendo a MM Juíza feito ao(a)(s) acusado(a)(s) a observação determinada no artigo 186 do Código de Processo Penal. INICIADOS OS TRABALHOS, com a concordância das partes, pela MM. Juíza foi(ram) colhido(s) o(s) depoimento(s) da(s) testemunha(s) (Francisco e Felipe) pelo sistema

virtual e, em seguida, interrogado(a)(s) o(a)(s) réu(ré)(s).

Em seguida, pela MM Juíza foi deliberado:

“Não havendo mais provas a serem produzidas, encerro a instrução, determinando às partes que passem aos debates orais:

Dada a palavra ao(à) ilustre representante do Ministério Público, manifestou-se sua Excelência nos seguintes termos:

"MM.Juíza, JOSE GABRIEL DA SILVA ALVES foi denunciado e está sendo processado como incurso no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, pois, no dia 27 de outubro de 2021, por volta de 08h58min, na Rua Marte, n.º 01, Jardim Planalto, nesta cidade e Comarca de Piracicaba/SP, trazia consigo, para entregar ou fornecer ao consumo de terceiros, ainda que gratuitamente, 117 (cento e dezessete) invólucros plásticos, em formas de “fiadas”, contendo crack, substância derivada da cocaína, com peso líquido de 11,1 (onze gramas e um decigrama), 41 (quarenta e um) eppendorfs contendo cocaína, com peso líquido de 9,4 (nove gramas e quatro decigramas), e 193 (cento e noventa e três) invólucros plásticos contendo Cannabis sativa L., maconha, com peso líquido de 183,4 (cento e oitenta e três gramas e quadro decigramas), sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

O processo teve andamento regular.

Devidamente notificado a fls. 114, o réu apresentou defesa prévia a fls. 118/121. A denúncia recebida a fls. 131/133. Durante a instrução, o réu foi interrogado e foram ouvidas as testemunhas arroladas.

É a síntese necessária.

A ação penal deve ser julgada procedente.

A materialidade delitiva está consubstanciada pelo auto de exibição e apreensão de fls. 09/10, fotografia de fls. 11, laudo de constatação de fls. 13/18 e laudo químico-toxicológico definitivo de fls. 128/130.

A autoria do crime descrito na denúncia restou também suficientemente comprovada.

Com efeito, o Guarda Municipal Felipe Vieira Alves, na Delegacia de Polícia, relatou: “que é guarda municipal nesta cidade e nesta data estava em patrulhamento de rotina com seu colega, momento em que visualizaram o indivíduo, posteriormente identificado como José Gabriel, parado na via pública, o qual ao visualizar a guarnição, tentou empreender fuga. Informou que foram ao encalço do indivíduo e durante abordagem, em sua posse, foi localizada uma pochete, cujo interior havia uma sacola plástica que armazenava 41 microtubos de substâncias aparentando ser cocaína, 193 porções de substâncias semelhante a maconha, 117 pedras de substância idêntica ao crack, além da quantia de R\$ 26,00 em notas trocadas. Disse que o indiciado, ao ser perguntado, alegou que encontrou a sacola com os entorpecentes e resolveu comercializar as drogas pelo local, bem como que já teria vendido algumas porções, mas não soube afirmar a quantidade exata. Diante dos fatos, foi dada voz de prisão ao indiciado e o conduziram até esta unidade policial, perante a autoridade, sendo necessário o uso de algemas pelo fundado receio de fuga (fls. 04).

Em juízo, o agente público prestou depoimento no mesmo sentido. Esclareceu que, no dia dos fatos, durante patrulhamento, em local conhecido como ponto de entorpecentes, visualizaram o réu parado e sozinho. Na ocasião, ao avistar os policiais, o acusado saiu correndo em sentido oposto, mas foi abordado. Realizada busca pessoal, apreenderam as drogas (maconha, crack e cocaína) e o dinheiro em seu poder, nos termos descritos na denúncia, em uma pochete. O réu, na ocasião, disse que havia encontrado os entorpecentes e resolveu vendê-los, sendo que o dinheiro era fruto da traficância. Informou, por fim, que não conhecia o acusado. Mesmo se dizendo usuário, o acusado foi enfático ao dizer que faria o comércio das drogas. No mesmo sentido foi o depoimento do Guarda Municipal Francisco Dernival Miranda Junior, tanto na Delegacia de Polícia (fls. 03) quanto em juízo, na audiência realizada nesta data. Na fase judicial, o agente público acrescentou que as drogas estavam embaladas e prontas para a comercialização.

O réu, interrogado na fase policial, negou a prática do delito. Alegou que: “estava passando pelo local, quando um desconhecido dispensou um saco plástico e resolveu pegá-lo, pois é usuário de drogas (maconha, crack e cocaína). Alegou que ficaria com a droga para consumo e que o valor localizada já estava no interior da pochete”

(fls. 05).

Em juízo, o acusado alegou que uma pessoa dispensou uma pochete, provavelmente ao avistar policiais, quando se apoderou dos bens, pois pretendia consumir os entorpecentes. Pouco depois, foi abordado pelos policiais. Disse que no interior desta pochete havia R\$ 26,00. Além disso, tinha R\$ 15,00, em seu bolso, dinheiro que havia recebido na reciclagem de latas. Negou, contudo, que pretendia vender os entorpecentes.

A versão apresentada, além de inverossímil, ficou isolada nos autos.

Dessa forma, analisando-se detidamente a prova pericial e oral produzida nos autos, verifica-se a imputação restou devidamente comprovada, na medida em que o conjunto probatório impõe a condenação, não apenas sob o enfoque da prova técnica produzida, mas, também, diante dos testemunhos dos guardas municipais.

No que tange à palavra dos agentes públicos, importante observar que foi corroborada pelos demais elementos de prova constantes dos autos, mormente pela apreensão das drogas em poder do acusado.

Portanto, merece valor o depoimento dos agentes públicos diante da coerência e harmonia com o restante do acervo probatório, além do que, sequer possuíam motivos para incriminá-lo.

Com efeito, “a simples condição de policial não torna a testemunha impedida ou suspeita” (STF, RTJ 68/64), de maneira que é “inaceitável a preconceituosa alegação de que o depoimento de policial deve ser sempre recebido com reservas, porque parcial. O policial não está legalmente impedido de depor e o valor do depoimento não pode ser sumariamente desprezado. Como todo e qualquer testemunho deve ser avaliado no contexto de um exame global do quadro probatório” (RT 530/372 e, no mesmo sentido, STRTJ 68/54).

Desse modo, considerando a quantidade de entorpecentes apreendidos, a forma de acondicionamento das substâncias, tudo confirmando pelos depoimentos judiciais, não há dúvidas de que as drogas se destinavam à comercialização.

Assim, comprovadas a materialidade e autoria delitiva a condenação é medida que se impõe.

No que tange à dosimetria da pena, verifica-se, inicialmente, que a quantidade e a diversidade de entorpecentes devem ser reconhecidas como circunstâncias judiciais desfavoráveis, nos termos do art. 42 da Lei nº 11.343/06. É certo, ainda, que o acusado é portador de maus antecedentes (além de ser reincidente), sendo condenado por ameaça e resistência nos autos n.º 0000419-76.2017.8.26.0599 (fls. 50/51 e 52: pena extinta em 30.06.20) e por roubo nos autos n.º 0004032-68.2014.8.26.0451 (fls. 51 e 52: pena extinta em 30.06.20); na adolescência, cumpriu medida socioeducativa pela prática de ato infracional análogo ao crime de roubo circunstanciado (fls. 54) e, atualmente, é processado pela prática de tentativa de furto nos autos n.º 1501216-36.2021.8.26.0599, pelo qual foi colocado em liberdade provisória no dia 17.08.2021 (fls. 51).

Na segunda fase, de rigor o reconhecimento da agravante da reincidência (CP, art. 61, inciso I), conforme acima indicado.

Na terceira fase de dosimetria, inexistem causas de aumento ou de diminuição de pena a serem valoradas.

Anoto que o acusado não faz jus a causa de diminuição de pena, do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, em razão da reincidência e porque a quantidade de drogas apreendidas, aliada às circunstâncias da prisão, além dos maus antecedentes, demonstra, nitidamente, a dedicação às atividades criminosas, não sendo criminoso pontual.

Destarte, incabível a incidência do privilégio.

Por fim, sendo certa a condenação, oportuno destacar ser vedada a conversão da pena privativa de liberdade em pena restritiva de direitos (artigo 44 da Lei nº 11.343/06) e que, com o advento da Lei nº 11.464/07, o regime inicial para o cumprimento de pena deve ser o fechado (artigo 2º, parágrafo 1º, da Lei nº 8.072/90).

Requeiro, por fim, seja decretado o perdimento do valor apreendido com o acusado, com fulcro nos artigos 61 e 63, ambos da Lei nº 11.343/2006.

Ante o exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO requer a condenação do réu JOSE GABRIEL DA

SILVA ALVES, nos termos da denúncia, julgando o pedido totalmente procedente. Dada a palavra ao(à) nobre defensor(a) do(a)(s) acusado(a)(s), manifestando-se sua Excelência nos seguintes termos:

"MM.Juiza, José Gabriel da Silva Alves foi denunciado como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06.

Segundo a denúncia (fls. 104-105), no dia 27 de outubro de 2021, por volta de 08h58min, na rua Marte, n.º 01, Jardim Planalto, nesta cidade e comarca de Piracicaba/SP, José trazia consigo, para entregar ou fornecer ao consumo de terceiros, ainda que gratuitamente, 117 (cento e dezessete) invólucros plásticos, em formas de "fiadas", contendo crack, substância derivada da cocaína, com peso líquido de 11,1 (onze gramas e um decigrama), 41 (quarenta e um) eppendorfs contendo cocaína, com peso líquido de 9,4 (nove gramas e quatro decigramas), e 193 (cento e noventa e três) invólucros plásticos contendo Cannabis sativa L., maconha, com peso líquido de 183,4 (cento e oitenta e três gramas e quadro decigramas), sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Ainda de acordo com a inicial, o réu trazia consigo entorpecentes para comercialização quando, notando a aproximação policial, tentou se evadir.

Imediatamente seguido e detido, os agentes encontraram em sua posse uma pochete contendo 41 (quarenta e um) eppendorfs de cocaína, 193 (cento e noventa e três) invólucros de maconha e 117 (cento e dezessete) pedras de crack, além de R\$26,00 (vinte e seis reais) (foto fls. 11). Informalmente, José disse que encontrou as drogas e decidiu vendê-las (fls. 03 e 04). Na delegacia, reafirmou ter encontrado os entorpecentes, mas negou comercialização (fls. 05).

Interrogado em solo policial, o réu "negou os fatos. Estava passando pelo local, quando um desconhecido dispensou um saco plástico e resolveu pegá-lo, pois é usuário de drogas (maconha, crack e cocaína). Ficaria com a droga para consumo e o valor localizado já estava no interior da pochete" (fls. 4).

Francisco Dernival Miranda Júnior, guarda municipal, narrou que: "estavam em patrulhamento de rotina, quando avistaram o indivíduo parado na via pública, que ao visualizar a guarnição, tentou empreender fuga. Foram ao encalço do indivíduo, o qual foi abordado e em sua posse foi localizada uma pochete. No interior dela havia uma sacola plástica que armazenava 41 microtubos de substância aparentando ser cocaína, 193 porções de substância aparentando ser maconha, 117 pedras de substância semelhante ao crack, além da quantia de R\$ 26,00 em notas trocadas.

Questionado, o indivíduo identificado como José Gabriel, contou que encontrou a sacola com os entorpecentes e resolveu comercializar pelo local, bem como que já teria vendido algumas porções, mas não soube declinar a quantidade exata. Diante dos fatos, deram voz de prisão ao indiciado, que foi conduzido até esta unidade policial, perante a autoridade, esclarecendo que foi necessário o uso de algemas pelo fundado receio de fuga" (fls. 3).

No mesmo sentido a versão apresentada pelo guarda municipal Felipe Vieira Alves (fls. 4).

Às fls. 50-53, juntada certidão de objeto e pé que indica a reincidência do requerido (autos n.º 0000419-76.2017.8.26.0599 - ameaça e desacato - trânsito em julgado para a Defesa em 27/2/2018; autos n.º 0004032-68.2014.8.26.0451 - roubo - pena cumprida em 31/7/2020).

- DA PRODUÇÃO DE PROVAS NOS AUTOS

A materialidade do delito se comprova pelo auto de exibição e apreensão de fls. 9-10, fotografia de fls. 11, laudo de constatação de fls. 13-18 e laudo de exame definitivo de fls. 128-130.

Com relação à autoria, em audiência de instrução foram colhidos os seguintes elementos:

a) Ouvido, inicialmente, o guarda municipal Felipe Vieira Alves. Estava em patrulhamento com o parceiro em local conhecido pelo tráfico. Visualizaram o réu, que tentou se evadir. Conseguiram abordá-lo logo a frente e, em revista pessoal, encontraram com o réu uma pochete com drogas (48 porções de cocaína, 193 de maconha e 117 de crack). O réu lhes disse que é usuário, tinha encontrado a droga e decidido vendê-la. O dinheiro (R\$27,00) que tinha consigo era fruto de uma venda já realizada. O réu lhe disse que encontrou a droga na praça onde ocorreu a prisão,

mas não detalhou onde. Não avistou outras pessoas junto do réu. Não conhecia o réu. Não se recorda se o réu disse ser pessoa em situação de rua.

b) Na sequência, foi ouvido Francisco Dernival Miranda Júnior, guarda municipal. Trouxe aos autos as mesmas informações do companheiro de farda.

c) Por fim, foi interrogado o réu José Gabriel da Silva Alves. Contou que a droga foi encontrada com ele. Um moleque saiu correndo e jogou. Deve ter avistado a polícia antes dele e fugiu. Pegou a droga no chão e a polícia o abordou. É usuário, estava no local para comprar droga. Estava em situação de rua e foi preso com o saco de material de reciclagem que cata para sobreviver ao seu lado. Não é verdade que disse aos policiais que estava vendendo a droga. Já tinha dinheiro dentro da pochete, não foi ele quem vendeu a droga. Não correu dos policiais, pois a hora que subiu um barranco após pegar a pochete, tentando despistar o traficante, e foi surpreendido pelo guarda Francisco. No seu bolso tinha R\$15,00. O resto do dinheiro, não sabe o que fizeram. Os R\$26,00 na pochete não eram seus. Não é verdade que disse aos policiais que ia vender as drogas. É usuário de cocaína e crack.

- DA ILICITUDE PROBATÓRIA: INCONSTITUCIONAL E ILEGAL ATUAÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL Inicialmente, deve ser reconhecida a ilicitude probatória, tendo em vista a atuação inconstitucional e ilegal da Guarda Municipal. Não bastasse, a atuação da GCM em atividade de policiamento ostensivo e investigativo, por si só, também é ilícita. Dessa maneira, a busca pessoal que resultou na apreensão das drogas foi oriunda de atuação da Guarda Civil Municipal.

Ocorre que, nos termos da Constituição Federal, art. 144, § 8º, a Guarda Municipal não tem competência para tanto. É no mesmo sentido a lição doutrinária (GASPARINI, Diógenes; As guardas municipais na constituição federal de 1988, Revista dos Tribunais. set./1991. v.671 p. 46-53; SILVA, José Afonso da. Comentário Contextual à Constituição, 3. ed. São Paulo: Malheiros, 2007, p. 638-9).

Por conseguinte, é inafastável a conclusão de que a apreensão dos entorpecentes, por guardas municipais, é medida ilícita, tornando imprestáveis, portanto, os elementos de prova daí decorrentes.

Em reforço, não há que se alegar que os guardas municipais teriam atuado legitimamente porquanto, nos termos do art. 301 do Código de Processo Penal, seria facultado a qualquer do povo efetuar a prisão em flagrante. In casu, não há que se falar em flagrante porquanto não houve qualquer motivação legítima para proceder à abordagem, eis que, conforme relatado pelas guardas municipais, logo após a visualização do imputado, elas efetuaram a abordagem imediatamente por considerarem que, ao visualizar a viatura, o réu “empreendeu fuga”. Os guardas sequer visualizaram a prática de qualquer atividade relacionada ao tráfico. O averiguado, portanto, não estava em situação de flagrância.

E, ainda que superado esse argumento, considerando-se legítima a prisão em flagrante, é certo que os guardas municipais carecem de competência para efetuar a busca pessoal, atividade típica de policiamento, vez que esta não é um desdobramento automático e necessário do flagrante. Tanto que a prisão em flagrante e a busca e apreensão são disciplinadas em seções autônomas do Código de Processo Penal, sendo que a busca pessoal somente será realizada quando houver “fundada suspeita” (CPP, art. 240, § 1º); enquanto a busca pessoal é uma medida de obtenção de prova, a prisão em flagrante é um ato pré-cautelar.

Ademais, o art. 241 c. c/ art. 244, ambos do Código de Processo Penal, estabelecem que a busca pessoal será conduzida pela autoridade policial. Assim, ainda que as guardas municipais, em razão do disposto no art. 144 da Constituição Federal, integrem a segurança pública, é certo que não podem ser considerados “autoridades policiais”; não por outra razão, quando efetuam a prisão em flagrante, fazem-no como “qualquer do povo”, com fundamento na parte inicial do art. 301 do Código de Processo Penal. Logo, para fins do art. 241 c. c/ art. 244, ambos do Código de Processo Penal, os guardas municipais não se equiparam às autoridades policiais. Assim, deparando-se com uma hipótese de flagrante, os guardas municipais devem apenas efetuar a custódia do indivíduo, encaminhando-o às autoridades policiais, sendo-lhes defeso efetuar a revista pessoal do cidadão detido.

Para melhor ilustrar, cite-se o habeas corpus n. 470.937-SP, em que o Superior

Tribunal de Justiça considerou ilícita a revista pessoal efetuada por agente de segurança privada. Extrai-se do referido julgado, aplicável ao presente caso por analogia, que, tal como os seguranças privados, os guardas municipais poderiam ter efetuado a custódia do indivíduo, atuando como “qualquer do povo” (CPP, art. 301), mas não a sua revista pessoal (HC 470.937-SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, por unanimidade, julgado em 04/06/2019, DJe 17/06/2019).

Em síntese, atuando como “qualquer do povo”, os guardas municipais podem, única e exclusivamente, efetuar a custódia de algum cidadão que esteja em situação de flagrante (CPP, art. 301), mas não podem efetuar a busca pessoal ou desenvolver atividades tendentes à obtenção de elementos de informação, sob pena de afronta ao disposto no art. 241 c. c/ art. 244, ambos do Código de Processo Penal, eis que, para esses fins, a despeito de estarem encarregados da segurança pública (CF, art. 144), não são considerados “autoridades policiais”. Nesse sentido, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça: (STJ, Habeas corpus 545.162/SP, Rel. Nefi Cordeiro, julgado em 4/2/2020).

Assim, tem-se que a apreensão das drogas, no caso sub examine, é elemento de prova ilícito, tendo em vista a inconstitucional atuação da Guarda Municipal. Por esse motivo, o auto de apreensão das drogas deverá ser desentranhado dos autos, eis que é inadmissível o seu ingresso no processo (CF, art. 5º, LVI c. c/ CPP, art. 157). E, por via de consequência, o laudo de constatação e o laudo de exame químico-toxicológico são provas ilícitas por derivação, não podendo servir para formação da convicção judicial, vale dizer, mostram-se incapazes para atestar a materialidade do delito imputado ao denunciado.

Desse modo, a absolvição, nos termos do art. 386, V, do CPP, é medida que se impõe.

- DA ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS

Caso se entenda pela licitude da atuação da GCM, de rigor a improcedência da pretensão acusatória. Isso porque, em audiência de instrução e julgamento, não foram produzidos elementos de prova que permitam concluir, além de qualquer dúvida razoável, pela responsabilidade penal do réu (CPP, art. 386, V e VII c. c/ art. 155).

Observa-se que, no caso concreto, eventual sentença de condenação estaria embasada apenas nas declarações dos guardas, elementos de prova de reduzido valor, tendo em vista a parcialidade de suas declarações. Nesse contexto, a jurisprudência do TJ-SP e a doutrina são pacíficos em lhes reconhecer o valor probatório, desde que confirmados por outros elementos de prova. Isso porque as declarações deles são tendentes a confirmar a sua própria atuação, motivo pelo qual se impõe cautela na sua apreciação (TJ-SP, 7ª Câmara de Direito Criminal, Apelação Criminal n. 0373088-52.2010.8.26.0000, Relator Sydnei de Oliveira Jr; TJSP – 7ª Câmara Criminal - Ap. 0020153-57.2006.8.26.0224 -- Rel. Francisco Menin – j. 03/02/11). Assim, seria necessário que fossem confirmadas por outros elementos de prova. E tal exigência não significa um demérito à atuação dos policiais; pelo contrário, reconhece-se a importante função que desempenham, mas se pugna que suas palavras sejam apreciadas com cautela, tendo em vista as suas condições e o histórico de violência institucional que caracteriza a polícia brasileira, como, aliás, reconhecido pela Corte Interamericana de Direitos Humanos, no Caso Cosme Rosa Genoveva vs. Brasil. Isso posto, conclui-se que os elementos de prova disponíveis nestes autos não são suficientes para superar o standard probatório da presunção de inocência, porquanto não permitem uma conclusão, além de qualquer dúvida razoável, sobre a responsabilidade penal do acusado. De rigor, por isso, que se decreta sua absolvição, na forma do art. 386, VII, do CPP.

- DAS ALEGAÇÕES RELATIVAS À DOSIMETRIA DA PENA

a) Da pena-base

Na remota hipótese de condenação, de rigor a fixação da pena-base em seu mínimo legal: as consequências e a culpabilidade são normais para o caso, não justificando uma reprovação penal maior.

No mais, as condenações anteriores devem ser avaliadas na segunda fase de fixação de pena, sob pena de bis in idem.

b) Da segunda fase da dosimetria

Na segunda fase, a agravante da reincidência deverá ser compensada com a atenuante

da confissão, ainda que seja apenas a informal, mantendo-se a pena no mínimo legal.

- DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA

No que tange ao regime inicial, em atenção ao disposto no art. 33, § 3º, diante da quantidade pena a ser aplicada e das circunstanciais judiciais, inexistindo fundamentação concreta a recomendar o regime mais gravoso (Súmulas 718 e 719 do STF; Súmula 440 do STJ), de rigor a aplicação do regime diverso do fechado. Adicionalmente, para a fixação do regime inicial, não poderá ser observado o disposto no art. 1º, § 2º, da LCH, tendo em vista que a declaração de inconstitucionalidade pelo STF, exercendo sua função típica de guardião da Constituição e, por isso, proferindo uma decisão de observância obrigatória por todo o Judiciário (CF, art. 102 c. c/ art. 927 do CPC).

- DO DIREITO DE APELAR EM LIBERDADE

Finalmente, deve ser assegurado ao acusado o direito de apelar em liberdade. De acordo com o art. 387, § 1º, do Código de Processo Penal, ao proferir uma sentença de condenação, "O juiz decidirá, fundamentadamente, sobre a manutenção ou, se for o caso, a imposição de prisão preventiva ou de outra medida cautelar, sem prejuízo do conhecimento de apelação que vier a ser interposta". Ademais, a decisão pela manutenção da prisão preventiva deve ser concreta, cabendo ao julgador "[...] indicar concretamente a existência de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida adotada" (CPP, art. 315, § 2º). Com efeito, uma vez encerrada a instrução, ainda que se entenda pela manutenção da prisão preventiva anteriormente exposta, a decisão deve ser concretamente fundamentada, visto que ainda vigente o estado de inocência (CF, art. 5º, LVII; CADH, art. 8.2).

No mais, no atual cenário, qualquer decisão que determina o recolhimento de alguém ao cárcere ou a manutenção de uma prisão anteriormente decretada deve ser ponderada à luz da crise sanitária causada pelo COVID-19. Considerando a situação emergencial de saúde pública decorrente do coronavírus (COVID-19), somada ao fato de que estabelecimentos em que há aglomeração de pessoas privadas de liberdade são muito mais suscetíveis à disseminação de doenças virais, e visando a reduzir ao máximo os riscos advindos de uma possível contaminação por coronavírus, principalmente dos sujeitos ainda protegidos pela presunção de inocência e acusados de crime não considerados graves, mostra-se imperiosa a concessão do direito de apelar em liberdade, caso o acusado seja condenado.

Em seguida pelo(a) MM.Juiz(a) foi dito o seguinte:

Passo a proferir a seguinte sentença:

VISTOS.

JOSE GABRIEL DA SILVA ALVES, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso nas penas do artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, porque no dia 27 de outubro de 2021, por volta de 08h58, na Rua Marte, n.º 01, Jardim Planalto, nesta cidade e Comarca de Piracicaba/SP, trazia consigo, para entregar ou fornecer ao consumo de terceiros, ainda que gratuitamente, 117 (cento e dezessete) invólucros plásticos, em formas de "fiadas", contendo crack, substância derivada da cocaína, com peso líquido de 11,1 (onze gramas e um decigrama), 41 (quarenta e um) eppendorfs contendo cocaína, com peso líquido de 9,4 (nove gramas e quatro decigramas), e 193 (cento e noventa e três) invólucros plásticos contendo Cannabis sativa L., maconha, com peso líquido de 183,4 (cento e oitenta e três gramas e quadro decigramas), sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Segundo a denúncia, o réu - que de longa data se dedica a atividades criminosas - trazia consigo entorpecentes para comercialização quando, notando a aproximação policial, tentou se evadir.

Imediatamente seguido e detido, os agentes encontraram em sua posse uma pochete contendo 41 (quarenta e um) eppendorfs de cocaína, 193 (cento e noventa e três) invólucros de maconha e 117 (cento e dezessete) pedras de crack, além de R\$26,00 (vinte e seis reais) (foto fls. 11).

Informalmente, José disse que encontrou as drogas e decidiu vendê-las (fls. 03 e 04). Na Delegacia, reafirmou ter encontrado os entorpecentes, mas negou comercialização (fls. 05).

Em exame pericial, foi constatada a presença de cocaína e Tetrahydrocannabinol nas substâncias apreendidas (auto de exibição fls. 09/10 e laudo pericial fls. 13/18).

Diante das circunstâncias, em especial a tentativa de fuga, a quantidade de droga incompatível com a mera destinação pessoal, as condições pessoais, a forma padronizada de embalo dos ilícitos e a apreensão de dinheiro em espécie, é certo que o réu trazia consigo os entorpecentes com a finalidade de comércio ilícito. A denúncia foi oferecida (fls. 103), sendo determinada a notificação do réu para oferecer defesa prévia, nos termos do artigo 55 da Lei nº 11.343/06 (fls. 106/107). Notificado (fls. 114), o réu apresentou defesa prévia, na qual requereu a revogação da prisão preventiva e, no mérito, alegou inocência (fls. 118/121).

A denúncia foi recebida, designando-se audiência virtual (fls. 131/133). O réu foi citado (fls. 150).

Durante a instrução, foram ouvidas duas testemunhas comuns, sendo o réu interrogado.

Encerrada a instrução, em memoriais, as partes se manifestaram.

É o relatório.

DECIDO.

I - Da preliminar

Pleiteia a Defesa, o reconhecimento da nulidade do processo, em razão da prisão realizada por guardas municipais. Argumenta que houve diligência típica de atividade policial, não permitida aos guardas municipais.

Não há, contudo, qualquer nulidade na prisão em flagrante do réu.

Não se verifica qualquer abuso ou ilegalidade na diligência efetuada pelos guardas municipais que, após avistar o réu sozinho, em local conhecido pela venda de drogas, além de ele ter empreendido fuga, foram no seu encalço e conseguiram detê-lo.

Por fim, a Lei nº 13.022/14 conferiu expressamente à Guarda Municipal a atribuição de polícia ostensiva, nos termos do artigo 3º da referida legislação, que assim dispõe: "Artigo 3º. São princípios mínimos de atuação das guardas municipais: I - proteção dos direitos humanos fundamentais, do exercício da cidadania e das liberdades públicas; II - preservação da vida, redução do sofrimento e diminuição das perdas; III - patrulhamento preventivo; IV - compromisso com a evolução social da comunidade; e V - uso progressivo da força".

De qualquer modo, nada obstante o disposto no artigo 144, parágrafo 8º, da Constituição Federal, é certo que, à luz do artigo 301 do Código de Processo Penal, não há uma proibição de que os guardas municipais prendam alguém em flagrante, haja vista que qualquer pessoa do povo também pode fazê-lo.

E, no caso concreto, ao contrário do postulado pela Defesa, o réu foi abordado na posse da droga, em local conhecido por ponto de droga, havendo flagrante, consoante prevê o artigo 302, inciso IV, do Código de Processo Penal.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça:

É assente nesta Corte Superior de Justiça a orientação de que os integrantes da guarda municipal não desempenham a função de policiamento ostensivo; todavia, em situações de flagrante delito, como restou evidenciado ser o caso, a atuação dos agentes municipais está respaldada no comando legal do art. 301 do Código de Processo Penal - CPP.[...] 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n.º 603.686/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 9/2/2021, DJe 17/2/2021) Ante o exposto, não conheço o presente habeas corpus. Intimem-se. Brasília, 25 de junho de 2021. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA Relator. (STJ - HC: 676532 SP 2021/0199414-0, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Publicação: DJ 29/06/2021).

"O recurso comporta parcial provimento. No caso, quanto à prisão em flagrante realizada por guardas municipais, inexiste ofensa aos alegados dispositivos de lei federal, pois o entendimento do Tribunal de origem alinha-se à jurisprudência desta Corte consolidada no sentido de que, "apesar das atribuições previstas no art. 144, § 8º, da Constituição Federal, se qualquer pessoa do povo pode prender quem quer que esteja em situação de flagrância, não se pode proibir o guarda municipal de efetuar tal prisão" (HC n. 286.546/SP, relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Sexta Turma, julgado em 22/9/2015, DJe de 15/10/2015). Nesse sentido, confira-se ainda: HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. INVASÃO DE DOMICÍLIO. ALEGAÇÃO DE

NULIDADE DAS PROVAS. CRIME PERMANENTE. FLAGRANTE DELITO. FUNDADAS RAZÕES. ATUAÇÃO DE GUARDAS MUNICIPAIS. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. [...] 4. "É assente nesta Corte Superior de Justiça a orientação de que os integrantes da guarda municipal não desempenham a função de policiamento ostensivo; todavia, em situações de flagrante delito, como restou evidenciado ser o caso, a atuação dos agentes municipais está respaldada no comando legal do art. 301 do Código de Processo Penal" (HC 471.229/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 19/2/2019, DJe 1º/3/2019) 5. Habeas Corpus não conhecido. (HC 525.772/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 17/10/2019, DJe 24/10/2019). Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso especial para, na segunda fase da dosimetria, compensar integralmente a agravante de reincidência com a atenuante de confissão, fixando a pena definitiva do paciente em 3 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial fechado, mais 11 dias-multa. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 24 de junho de 2021. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Relator (STJ - REsp: 1940142 SP 2021/0159530-8, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Publicação: DJ 28/06/2021).

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO E USO DE DOCUMENTO FALSO. PRISÃO FLAGRANCIAL ILEGAL. GUARDA MUNICIPAL PODE PROMOVER PRISÃO EM FLAGRANTE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A primeira parte do art. 301 do Código de Processo Penal autoriza a qualquer do povo prender quem quer que seja encontrado em flagrante delito. Desse modo, inexiste ilegalidade na prisão em flagrante realizada por guardas municipais. 2. Conforme compreensão da Sexta Turma desta Corte Superior, havendo fundada suspeita a configurar situação de flagrante delito, mostra-se lícita a abordagem pessoal feita pela Guarda Civil Municipal, que não atua, nessa hipótese, como polícia investigativa. 3. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC: 667413 SP 2021/0152075-9, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 01/06/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/06/2021)

Nesse sentido também o Tribunal de Justiça de São Paulo:

PRELIMINAR. ILICITUDE DAS PROVAS. BUSCA PESSOAL REALIZADA POR GUARDAS CIVIS MUNICIPAIS. FALTA DE COMPETÊNCIA PARA O ATO. INEXISTÊNCIA. O Estatuto das Guardas Municipais (Lei nº 13.022/14), regulamentou o artigo 144, § 8º, da Constituição Federal, estabelecendo que compete à Guarda Civil Metropolitana, entre outras atribuições, prevenir, inibir e coibir infrações penais, bem como encaminhar indivíduos em flagrante delito à autoridade policial (art. 5º, II, III e IV da referida Lei). Ademais, como qualquer do povo, esses servidores podem efetuar a prisão em flagrante do agente cuja conduta se amolde às hipóteses taxativas do artigo 302 do Código de Processo Penal. Guardas civis municipais que foram alertados por transeunte sobre a conduta do réu, dirigiram-se ao local, observaram a prática de atos típicos de traficância e efetuaram sua prisão em flagrante delito. Ausência de ilicitude da busca pessoal que culminou na apreensão das drogas e dinheiro e o início da persecução penal. Preliminar rejeitada. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. CONDENAÇÃO MANTIDA. Materialidade e autoria bem demonstradas nos autos. Guardas civis, após denúncia de traficância, avistaram o réu Yan em movimentação típica de tráfico com dois indivíduos e o surpreenderam na posse de duas porções de cocaína, vindo a localizar, no local de onde empreendera fuga, outras cinco porções da mesma droga, idênticas, e R\$ 20,00. Silente na fase extrajudicial, apelante negou em juízo o tráfico de drogas. Negativa e versão judiciais, além de fantasiosas e inverossímeis, sucumbiram à prova produzida pela Acusação. Condenação mantida. PENAS. Base fixada no mínimo legal. Pleito ministerial atendido para reconhecer-se a agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea "j", do Código Penal, haja vista a prática do crime durante o estado de calamidade pública da pandemia de COVID-19, mormente no caso dos autos, em que se apura crime que visa a resguardar a saúde pública. Mantido o reconhecimento da reincidência. Negada a aplicação do redutor, por vedação legal expressa. Pena majorada. REGIME PRISIONAL. Regime inicial fechado mantido, ante a quantidade de pena aplicada e a reincidência específica, além da gravidade concreta do delito praticado. Regime inicial fechado mantido. BENEFÍCIOS LEGAIS. Incabíveis o sursis penal e a substituição da pena

corporal por restritiva de direitos, ante a quantidade de pena corporal (superior a quatro anos) e a reincidência específica do réu. Preliminar rejeitada e, no mérito, apelo defensivo desprovido, com provimento ao recurso ministerial para, reconhecida a agravante prevista no art. 61, II, "j", do Código Penal, redimensionar suas penas para 6 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa mínimos, com expedição de ofício de recomendação em seu desfavor. (TJ-SP - APR: 15015986320208260599 SP 1501598-63.2020.8.26.0599, Relator: Gilda Alves Barbosa Diodatti, Data de Julgamento: 29/06/2021, 15ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 29/06/2021 - grifei).

"Pondera-se, também, que em casos como o dos autos, por ser o tráfico de drogas um delito permanente, possível é a prisão flagrancial, a qualquer tempo e por qualquer um do povo, a teor do que dispõe o art. 301 do Código de Processo Penal. Destarte, não há impedimento legal para que membro da Guarda Civil Metropolitana efetue prisões em flagrante. Nesse sentido é a jurisprudência do col. Superior Tribunal de Justiça: HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. FLAGRANTE EFETUADO POR GUARDA MUNICIPAL. VALIDADE. ART. 312 DO CPP. PERICULUM LIBERTATIS. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. COVID-19. RECOMENDAÇÃO N. 62/2020 DO CNJ. INAPLICÁVEL. ORDEM DENEGADA.1. Conforme já decidiu esta Corte Superior, é possível que, diante de notícia criminis, envolvendo qualquer dos bens jurídicos mencionados, o agente municipal proceda à atividade de vigilância no local indicado para se certificar de sua veracidade, hipóteses nas quais, de nenhum modo, estaria desautorizado a agir. 2. A situação de flagrância delitiva legitima a atuação de "qualquer pessoa do povo" a proceder à prisão, oportunidade em que é perfeitamente possível a realização da abordagem do suspeito, não sendo diferente em relação àqueles agentes que, ao realizarem seu mister de zelar pelo patrimônio público, muitas vezes se deparam com infrações penais, sendo-lhes lícito atuar em tais ocasiões. Precedentes. [...] 8. Ordem denegada. (HC 583.610/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 04/08/2020, DJe 14/08/2020). PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO CONFIRMADA PELO TRIBUNAL A QUO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. ALEGAÇÃO DE PROVA ILÍCITA. CONDUTA FLAGRADA POR GUARDAS MUNICIPAIS. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. [...] III - O reconhecimento de nulidades no curso do processo penal reclama uma efetiva demonstração do prejuízo à parte, sem a qual prevalecerá o princípio da instrumentalidade das formas positivado pelo art. 563 do CPP (pas de nullité sans grief). IV - Firme o entendimento jurisprudencial deste Superior Tribunal de Justiça no sentido de que: "Nos termos do artigo 301 do Código de Processo Penal, qualquer pessoa pode prender quem esteja em flagrante delito, razão pela qual não há qualquer óbice à sua realização por guardas municipais. Precedentes." (HC 357.725/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, DJe 12/5/2017). [...] Habeas corpus não conhecido. (HC 480.676/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 21/03/2019, DJe 28/03/2019). RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PRISÃO EM FLAGRANTE EFETUADA POR GUARDAS MUNICIPAIS. PROVAS ILÍCITAS. INOCORRÊNCIA. 1. Não há falar em ilegalidade da prisão em flagrante e, consequentemente, em prova ilícita, porque efetuada por guardas municipais, que estavam de ronda e foram informados da ocorrência da prática de tráfico de drogas na ocasião, se pode fazê-lo qualquer do povo (artigo 301 do Código de Processo Penal). 2. Recurso improvido. (RHC 20.714/SP, Rel. Ministro HAMILTON CARVALHIDO, SEXTA TURMA, julgado em 10/05/2007, DJe 04/08/2008). (TJ-SP - RVCR: 22502921020198260000 SP 2250292-10.2019.8.26.0000, Relator: João Morenghi, Data de Julgamento: 29/06/2021, 6º Grupo de Direito Criminal, Data de Publicação: 29/06/2021- grifei).

Apelação da Defesa – Tráfico de Drogas – Preliminar de nulidade – Ilegalidade da prisão, efetuada por guardas civis – Réus em situação de flagrância, cuja prisão pode ser efetuada por qualquer pessoa – Artigo 301 do CPP – Preliminar rejeitada – Provas suficientes à condenação – Materialidade e autoria comprovadas – Circunstâncias reveladoras do crime de tráfico de entorpecentes – Apreensão de significativa quantidade de maconha em poder dos acusados – Fator que, associado à prova produzida, leva à conclusão de que os entorpecentes eram destinados ao consumo de terceiros – Penas-base fixadas em seus patamares mínimos – Circunstância

atenuante da menoridade relativa reconhecida, mas sem reflexo nas penas - Inaplicabilidade do redutor previsto no artigo 33, § 4º, da Lei Antidrogas - Redução que deve se voltar às hipóteses em que o acusado não faz da narcotraficância seu meio de vida - Regime inicial fechado mantido - Impossibilidade da fixação de regime aberto e da substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos - Mercês incompatíveis com delitos de singular gravidade - Necessidade de maior repressão ao tráfico de entorpecentes - Rejeitada a preliminar, recursos de apelação desprovidos. Apelação da Justiça Pública - Associação para o tráfico de drogas - Fragilidade do conjunto probatório - Circunstâncias que parecem indicar mero concurso eventual de agentes e não associação de cunho permanente - Absolvição mantida - Colaboração com o tráfico de drogas na condição de informante - Hipótese de coautoria - Ré que decidiu atuar na venda de drogas em comparsaria com sua companheira, havendo a divisão de tarefas e de lucros entre ambas - Crime subsidiário aplicável somente à colaboração eventual e desvinculada do efetivo comércio de entorpecentes - Condenação pelo crime do artigo 33, "caput", da Lei n. 11.343/2006 - Pena-base fixada em seu patamar mínimo - Circunstância atenuante da menoridade relativa reconhecida, mas sem reflexo na pena - Inaplicabilidade do redutor previsto no artigo 33, § 4º, da Lei Antidrogas - Redução que deve se voltar às hipóteses em que o acusado não faz da narcotraficância seu meio de vida - Regime inicial fechado - Impossibilidade da fixação de regime aberto e da substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos - Mercês incompatíveis com delitos de singular gravidade - Necessidade de maior repressão ao tráfico de entorpecentes - Recurso de apelação parcialmente provido. (TJ-SP - APR: 15029258520198260079 SP 1502925-85.2019.8.26.0079, Relator: Cesar Augusto Andrade de Castro, Data de Julgamento: 25/06/2021, 9ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 09/06/2021)

II - Do mérito

No mérito, a ação penal é procedente.

1) Da materialidade

A materialidade criminosa está consubstanciada no auto de exibição e apreensão de fls. 09/10, na fotografia de fls. 11, no laudo de constatação de fls. 13/18, bem como no exame químico-toxicológico de fls. 128/130, segundo o qual foi detectada a presença das substâncias cocaína e Tetrahidrocannabinol (THC) nas substâncias apreendidas.

2) Da autoria

A autoria ficou demonstrada nos autos.

Na fase investigativa, o réu disse que estava passando pelo local, quando um desconhecido dispensou um saco plástico e resolveu pegá-lo, pois é usuário de drogas (maconha, crack e cocaína). Ficaria com a droga para consumo. O valor localizado já estava na pochete. É ajudante de pedreiro, mas está desemprego e mora na rua, mas quando trabalha, ganha R\$ 80,00 por dia (fls. 05).

Em Juízo, o réu afirmou que a droga foi encontrada consigo, porque o moleque, um pouco antes, correu e jogou a droga. Pegou a pochete para usar a droga. Iria usar a droga e não vendê-la. Tinha R\$ 15,00 em seu bolso, que lhe pertencia. Estava morando na rua, porque a irmã tem medida protetiva. O moleque conseguiu fugir. O verdadeiro traficante conseguiu fugir. Só ele foi abordado. Não disse que estava vendendo a droga. Já tinha dinheiro dentro da pochete. No momento em que colocou a pochete na cintura e abaixou a camisa, para o traficante não ver, os guardas já o abordaram. Não correu dos guardas civis. Não viu os guardas civis se aproximando. Os R\$ 26,00 não lhe pertenciam, só tinha R\$ 15,00. Negou aos guardas civis que tivesse vendendo drogas. Tanto que nem foi revistado. Faz uso de cocaína e crack e consegue ficar sem consumi-los. Só tinha ido comprar drogas. Não tem nada a ver com a droga, embora ela estivesse em seu poder.

A autoria restou comprovada nos autos, conforme se verifica das provas. Vejamos. O guarda municipal Francisco Dernival Miranda Junior relatou que passavam pelo local e o réu, que estava perto de uma praça e sozinho, ao perceber a aproximação, tentou fugir correndo, mas foi abordado. Na posse do réu, havia uma pochete, dentro da qual havia uma sacola, com maconha, crack e cocaína, além de R\$ 26,00. Toda a droga já estava embalada. Indagado sobre a droga, o réu falou que tinha achado a

droga e resolveu vendê-los, para adquirir dinheiro. O local é conhecido como ponto de venda de drogas. Não conhecia o réu. Não chegou ao seu conhecimento que o réu estava em situação de rua. O réu falou que tinha encontrado as drogas e que resolveu vendê-las.

No mesmo sentido, o depoimento do também guarda municipal Felipe Vieira Alves esclareceu que estavam em patrulhamento, quando, em rua conhecida como ponto de venda de drogas, avistaram o réu parado na via pública, sozinho. Assim que avistou a viatura, o réu começou a correr no sentido oposto da direção em que estavam, mas foi acompanhado e abordado. Em revista pessoal, encontraram com o réu crack, maconha e cocaína e R\$ 26,00, que estavam dentro da pochete, fixada na linha da sua cintura. Indagado sobre os fatos, o réu afirmou que tinha encontrado aquela droga escondida, naquela praça, e que a estava vendendo, inclusive o dinheiro era produto dessa venda ilícita. Não conhecia o réu. O réu disse que era usuário de drogas e também iria usá-la, mas foi enfático em dizer que também a venderia. Não se recorda se o réu estava em situação de rua.

A primeira questão a ser analisada nos autos é o envolvimento do réu com a droga apreendida.

Em solo policial, o réu confirmou a posse da droga, dizendo que as teria encontrado. Em Juízo, o réu contou que a droga estava em seu poder, mas seria usada para seu consumo.

Os guardas municipais narraram que avistaram o réu parado, sozinho, em ponto de venda de drogas e, quando se aproximaram, ele tentou empreender fuga, saindo correndo. Em razão desses fatos, foram no encalço do réu e conseguiram abordá-lo. Em revista pessoal, com o réu, encontraram uma pochete, dentro da qual havia 41 microtubos de cocaína, 193 porções de maconha, 117 pedras de crack e R\$ 26,00, em notas trocadas. Indagado, o réu confessou que havia encontrado a sacola com os entorpecentes e resolveu comercializá-los no local, acrescentando que já teria vendido algumas porções, cuja quantidade exata não soube informar.

Existe apenas uma versão sobre a posse da droga, exatamente a de que o réu estava na posse da pochete, dentro da qual estavam as drogas apreendidas. Não resta, portanto, qualquer dúvida sobre essa situação.

Ainda que assim não fosse, a palavra dos guardas municipais, como funcionários públicos que são, tem validade como prova, a menos que haja alguma prova de que têm interesse no resultado da demanda penal. Ressalto que o depoimento dos agentes foi firme, unânime e inquestionável.

Nesse sentido, já se manifestou o Egrégio Superior Tribunal de Justiça:

(...) 7. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento firme de que os depoimentos dos policiais, que acompanharam as investigações prévias ou que realizaram a prisão em flagrante, são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. (...) (AgRg no AREsp 918.323/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 19/11/2019, DJe 26/11/2019). (...) IV - O depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso. Precedentes. (...) (HC 471.082/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 23/10/2018, DJe 30/10/2018).

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO. PALAVRA DE POLICIAIS. PROVA PARA A CONDENAÇÃO. VALIDADE. INSUFICIÊNCIA DO ACERVO PROBATÓRIO. INVIABILIDADE DE ANÁLISE NA VIA ESTREITA DO HABEAS CORPUS. WRIT NÃO CONHECIDO. I - A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do col. Pretório Excelso, firmou orientação no sentido de não admitir a impetração de habeas corpus em substituição ao recurso adequado, situação que implica o não conhecimento da impetração, ressaltados casos excepcionais em que, configurada flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal, seja possível a concessão da ordem de ofício. II - O depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a

imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso. Precedentes. III - Ademais, no caso dos autos, constou do v. acórdão vergastado que os depoimentos dos policiais são corroborados por outros elementos probatórios, notadamente a apreensão de considerável quantidade de crack